

1512775-81.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico - Tráfico bem caracterizado pelas provas dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512775-81.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512775-81.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2246864/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 20166856 - 03º D.P. AMERICANA, 1322/21/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2246864 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1322/21/346 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO VINICIUS VICENTE DA ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MARCO VINICIUS VICENTE DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (47 porções de maconha, pesando 49,4g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 120/121, foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 200/201).

O réu foi citado (fls. 181), apresentando defesa (fls. 189/191).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 247/248).

Em seus memoriais (fls. 252/254), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 255/257), requereu a absolvição por falta de provas, ou a fixação da pena mínima.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 85/87 e fls. 138/163.

Não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticos, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem

consequências desastrosas. (os grifos são meus).

A autoria é indubitável.

O réu foi preso em flagrante, o que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que receberam uma denúncia anônima acerca de um indivíduo, com blusa azul e bermuda preta, que estaria praticando o tráfico, pegando a droga escondida na calha de uma casa. Dirigiram-se então ao local, e localizaram um indivíduo com as mesmas características. Em abordagem, e em revista pessoal, com o réu localizaram a quantia em dinheiro. Em vistoria na residência, na calha, foram localizadas as 47 porções aparentando tratar-se de maconha e, questionado, o réu negou a propriedade da substância entorpecente. Declararam, também, que posteriormente, o denunciante encaminhou a Delegacia as filmagens, onde o réu foi reconhecido, inclusive em razão das vestes, e é possível vê-lo entregando algo a terceiros. Por fim, o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência

nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência: Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Impetração visando a absolvição do apelante por fragilidade probatória, com base na negativa de autoria e nas contradições existentes nas versões dos policiais - IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade comprovadas - Negativa de autoria isolada nos autos - Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória - Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos” (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida O agente da polícia serve como

testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a juízo para perseguir sistematicamente pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - 18.08.94)

A quantidade de tóxico apreendida, bem a quantia em dinheiro, além da denúncia/filmagens, evidenciam a destinação de tráfico.

O acusado Marco, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, alegando havia acabado de sair de sua casa e encontrou uns amigos, quando foi abordado pelos policiais. Disse, ainda, que foi liberado pelos policiais e novamente abordado. Por fim, não estava com blusa azul, sendo outras pessoas que estavam com a vestimenta.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Por fim, o fato do réu já ter sido processado por delito de igual natureza, o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, é indicio que fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, e do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a existência de antecedentes, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto) e a fixo em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente específico, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 39/50.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:
STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006, tendo em conta a natureza da droga e a quantidade apreendida. Além disso, o dispositivo é inaplicável ao réu reincidente, ex vi legis.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Uma porque o réu é reincidente específico, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Regime fechado. Tratando-se de réu reincidente específico, posto que agora condenado a pena de cinco anos de reclusão, outro não há de ser regime prisional de cumprimento inicial que o fechado. (TJSP; Apelação Criminal 0001074-91.2017.8.26.0617; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso da Defesa - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas - Inadmissibilidade - Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado

trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Regime prisional mais brando – Inadmissibilidade - Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente, merecendo tratamento penal mais severo – (...) - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500257-28.2018.8.26.0613; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Além disso, nos termos do entendimento da jurisprudência (TJSP, 993.07.126969-7, 6ª Câmara, Rel. Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. 25.02.201), de acordo com a Lei nº. 11.464, de 28 de março de 2007, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise do eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão. Se assim não fosse, não teria sentido algum outro regime a ser fixado. O legislador, ao tratar o traficante de drogas equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis, como fiança, indulto, sursis, liberdade provisória etc. Assim, não faria sentido que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso ao fechado.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS – CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO, AINDA QUE EM SUA MODALIDADE "PRIVILEGIADA". REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1) A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos – Precedente do C. STJ – Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos. 2) Substituição da corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de pena restritiva de direitos – Art. 44, III, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0009095-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)

Assim também se posicionou a 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“No tocante ao regime prisional, deve prevalecer o fechado, por força de expressa previsão legal e o montante das penas carcerárias inviabiliza eventual substituição por restritivas de direitos. Afinal, os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade ordeira”. (Relator Des. Roberto Mortari, j. 22.05.2014).

O réu não pode apelar em liberdade por vedação expressa contida no artigo 44 da Lei 11.343/2006.

Além disso, o delito de tráfico de entorpecentes é considerado como crime hediondo nos termos da Lei 8.072/90. A gravidade do delito não autoriza a concessão do benefício. O entendimento jurisprudencial não é diverso: Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória proferida em 01/10/2019 – Impetração pleiteando a concessão do direito de apelar em liberdade – Impossibilidade – Custódia cautelar suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, o paciente registra maus antecedentes e é reincidente específico – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal – Ademais, não há sentido em que o réu, que permaneceu preso

durante toda a fase instrutória, seja solto quando da prolação da sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2283715-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

"Associação para a prática de tráfico de entorpecente (art. 14 da lei n 6.368/76) - condenação judicial - Recusa do benefício de apelar em liberdade - Inexistência de constrangimento ilegal - Irrelevância de inaplicável à espécie a regra do art. 35 da Lei 6.368/76, que proíbe o apelo em liberdade tão-só nos casos de condenação pelos delitos dos arts. 12 e 13. O benefício de apelar em liberdade pode ser validamente recusado a quem sofrer condenação penal pela prática do delito de associação criminosa, tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76. A extrema gravidade objetiva desse fato e as circunstâncias pertinentes ao crime e à personalidade do agente constituem elementos a que os juízes e tribunais não podem ficar indiferentes. A periculosidade do agente encontra-se insita na própria ação criminosa por ele desenvolvida, em face da grave repercussão social de que se reveste qualquer comportamento ilícito associado ao tráfico de entorpecentes. O fato de ser inaplicável ao paciente a regra inscrita no art. 35 da Lei Antitóxicos não inibe o magistrado de recusar-lhe o benefício da apelação em liberdade, desde que o faça em ato decisório plenamente motivado". - HC n 67.750-9 - SP - 1ª T. do S.T.F. - j. 28.11.89 - Rel. Min. CELSO DE MELLO (RT. 652/382).

No mesmo sentido: RT 653/296, 655/350, 646/342 e 297, 627/281 e 347, 630/300, 633/386, 634/319, 636/295, 591/387, RJTJESP 120/586, 116/535.

O fomento que esse tipo de delito traz à prática de outros tipos de delito exige a manutenção do réu no cárcere, para a garantia da ordem pública. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, acrescentando que, no caso do réu, já foi condenado por outro delito, falta o requisito da suficiência.

Além disso, o réu Marco encontra-se preso por força de prisão em flagrante, e segundo a melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que "Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais" (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para este - Pleito visando o direito de apelar em liberdade – Inadmissibilidade - Existência nos autos de prova da materialidade do delito e, em tese, indícios de autoria – Decisão fundamentada de forma suficiente – Acusada que foi presa em flagrante, permaneceu custodiada ao longo de toda a instrução e, ao final, foi condenada – Fatores impeditivos da almejada liberdade para apelar em liberdade - Presença dos requisitos da prisão preventiva - Inexistência de constrangimento ilegal - Denegação da ordem. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2172499-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.02.2012).

E, no caso sub judice persistem os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois os delitos apurados roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade". (AC 2018.0000350330, Habeas Corpus nº 2062136-72.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. França Carvalho, 10 de maio de 2018)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MARCO VINICIUS VICENTE DA ROCHA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos valores e objetos apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Por fim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela Defesa a fls. 257, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.
P. R. I. C.

Americana, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA